

1102604-18.2020.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Franquia

Magistrado: Eduardo Palma Pellegrinelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... oportunistas prejudiciais ao tráfico. O princípio do "pacta sunt servanda" mostra-se necessário ao giro mercantil na medida em que freia o natural oportunismo dos agentes econômicos" (op. cit. - grifado).

Conclui-se, assim, que o insucesso da parte autora não pode ser atribuído à ré sem que tenha sido, sequer, demonstrado o inadimplemento do contrato, restando portanto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Praca Doutor Joao Mendes, S/N, São Paulo - SP - cep 01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1102604-18.2020.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1102604-18.2020.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Franquia

Requerente:

André Barcelos Nardoto e outros

Requerido:

Partmed Franchising Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Palma Pellegrinelli

Vistos.

1. Relatório

Trata-se de ação promovida por ANDRÉ BARCELOS NARDOTO, LUDMILA ROCHA DUTRA e LA MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA. ME contra PARTMED FRANCHISING LTDA visando a anulação ou, subsidiariamente, a rescisão do contrato de franquia firmado entre as partes por culpa da franqueadora, com a condenação desta a "assumir a operação das lojas sob pena de os autores promoverem o imediato encerramento", bem como "à Devolução da taxa de franquia e de todo o capital investido em decorrência da anulabilidade ou rescisão"; e, "[n]a remota hipótese de se entender ser devido algum valor à ré[-reconvinte], apenas por amor à argumentação", a declaração de "redução da multa contratual reduzida para ½ taxa de franquia"; e a condenação da franqueadora ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e ao pagamento de multa contratual (fls. 01/40), na qual houve a propositura de reconvenção visando a condenação dos franqueados "ao pagamento do valor total de R\$ 3.035,11 (três mil e trinta e cinco reais e onze centavos), a título de Royalties, que se encontra em

aberto, além dos percentuais de Royalties que se vencerem no curso da presente demanda", bem como ao pagamento "da multa rescisória (cláusula 18.3 do Contrato), no importe de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão da rescisão do Contrato de Franquia de forma prematura e injustificada" (fls. 505/542);

Alegam os autores, em síntese, que ANDRÉ e LUDMILA "sempre atuaram na área da saúde, no setor de prestação de serviços médicos e odontológicos"; que, nesse contexto, ao procurar "opções de investimento", conheceram a ré e, em 02 de janeiro de 2018, as partes pactuaram o contrato de franquia visando a operação de unidade da rede de "clínicas médicas populares" Partmed; e que o referido contrato padeceria de vícios de nulidade, em razão da omissão de informações obrigatórias na circular de oferta de franquia, bem como em razão da prestação de informações "inverídicas", estando subsidiariamente configurada a hipótese de rescisão por culpa da franqueadora, em razão do inadimplemento de obrigações desta quanto à prestação de serviços de treinamento e suporte técnico. Em particular, alegam que a franqueadora selecionou local inadequado para a instalação da unidade franqueada, "sem nenhum estudo geomercadológico", impondo assim "projeto arquitetônico elaborado pela franqueadora, excedendo mais de R\$ 180.000,00 o valor combinado para este fim" e demora de um ano na inauguração da unidade; que "não houve nesse período inicial nenhum suporte da ré[-reconvinte], conforme prometido antes da assinatura do contrato de franquia, fato que preocupou os autores[-reconvindos], tendo que assumir a obra sem nenhuma experiência"; que a ré-reconvinte "prometeu, via contrato de franquia, um faturamento mensal bruto de R\$ 406.000,00 e líquido de 27,2% deste valor, sendo o ponto de equilíbrio a partir do oitavo mês e o retorno de investimento em dezenove meses"; que o consultor enviado pela franqueadora para a inauguração permaneceu por tempo insuficiente e, posteriormente, após pedidos dos franqueados, a franqueadora enviou consultores despreparados, os quais causaram "sérios problemas aos autores[-reconvindos]"; que "como o custo estimado pela ré[-reconvinte] no contrato de franquia foi muito além do que os autores[-reconvindos] previram, (...) [estes tiveram] que se socorrer a empréstimos pessoais para poderem prosseguir com o negócio"; que, posteriormente, constataram a existência de reclamações de outros franqueados na plataforma online Reclame Aqui; que "nos quinze meses de operações, apenas três meses os autores não ficaram no vermelho" e nunca obtiveram "o lucro prometido pela ré de aproximadamente R\$ 110.000,00 mensais"; que "a resposta da franqueadora para qualquer pedido de suporte dos autores sempre foi da necessidade de investirem mais dinheiro"; que, em suma, a operação proposta pela franqueadora é "inviável"; e que a conduta da franqueadora ocasionou danos materiais e morais passíveis de reparação em favor dos franqueados, bem como a inexigibilidade de débitos a título de royalties e outras taxas e obrigações decorrentes do contrato pactuado e, ademais, a exigibilidade de "multa contratual reversa em favor dos autores[-reconvindos]". Alegam, por fim, que a cláusula de não-concorrência estipulada no contrato "é completamente abusiva, e onerosa, por isso, não podem os autores estarem sujeitos à esta"; que, na hipótese de improcedência da demanda quanto aos pleitos de anulação e rescisão, é cabível a redução proporcional da multa contratual; e que o contrato pactuado entre as partes seria "contrato de adesão" e os franqueados seriam hipossuficientes, de modo que configurada hipótese para a inversão do ônus da prova.

A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 41/478).

Considerando as peculiaridades do caso, foi facultada à parte ré-reconvinte a manifestação sobre a tutela de urgência (fls. 480/481), sobrevivendo o comparecimento espontâneo desta, com manifestação (fls. 486/492).

Foi indeferida a tutela de urgência (fls. 497/501), sobrevivendo o v. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos autores-reconvindos contra esta decisão (fls. 1.175/1.187).

Por ocasião da resposta com reconvenção (fls. 505/542), foram alegadas,

preliminarmente, a inépcia da petição inicial, a impugnação ao valor da causa e a decadência do direito quanto ao pedido de anulação do contrato de franquia. No mérito, foi alegado, em síntese, que os franqueados “tentam transferir para a Ré[-reconvinte] os riscos empresariais de sua empreitada, sendo que a jurisprudência é pacífica que o risco não é do franqueador”; que não houve promessa de lucro; que da circular de oferta de franquia “consta, expressamente, a possibilidade de variação de valores, em virtude de mudanças econômicas, geográficas, das condições do imóvel, da localização e do ponto, restando incontroverso que os Franqueados locaram um imóvel que, como por eles mesmos afirmado, não detinha as instalações básicas, sendo necessária mais do que uma adaptação do imóvel, já que não possuía características compatíveis com uma clínica médica, o que não é abarcado pela COF”; que a franqueadora cumpriu todas as suas obrigações contratuais e inexistem vícios na circular de oferta de franquia entregue aos franqueados; que, por outro lado, franqueados “estão INADIMPLENTES com o pagamento das taxas contratuais estipuladas, tal como Royalties”, no valor de R\$ 3.035,11; que o contrato ainda está sendo executado; e que, portanto, inexistente culpa da franqueadora por uma eventual rescisão do contrato. Nesse sentido, foi ainda alegado que, ainda que houvesse vícios na circular de oferta de franquia, estes estariam convalidados pela execução voluntária do contrato pelos franqueados; que as alegações de inadimplemento contratual foram formuladas pelos franqueados “de forma genérica e sem comprovação”; que “os próprios Requerentes afirmaram em sua peça inaugural, QUE RECEBERAM OS MANUAIS (fls. 440/450), OS TREINAMENTOS E A ASSESSORIA, COM ORIENTAÇÕES IN LOCO E À DISTÂNCIA, juntando aos autos inúmeros e-mails trocados (fls. 384/403), que comprovam que sempre houve uma dialética entre eles e a PARTMED, que os atendeu em todas as oportunidades em que fora demandada”; que, na eventualidade de extinção do contrato, são exigíveis as obrigações de abstenção de uso da marca Partmed e de não-concorrência, “retornando os Franqueados ao seu antigo modelo de negócio, por, pelo menos 2 (dois) anos, não atuando direta ou indiretamente no mesmo lugar ou em qualquer outro, de acordo com a vedação à concorrência e do efeito positivo da marca sobre o negócio no local”, inexistindo abusividade, posto que ressalvada aos franqueados “a possibilidade de continuarem atuando dentro de sua profissão, desde que de forma autônoma”; que “não há qualquer previsão contratual no sentido de que a Franqueadora assumira a unidade franqueada, se os Autores não querem mais possuir a clínica, que encerrem de acordo com o que é previsto no Contrato”; que a ré não praticou quaisquer atos que tenham ensejado danos morais ou materiais aos franqueados; que o contrato pactuado entre as partes “possui natureza estritamente comercial”, não sendo aplicável portanto a inversão do ônus da prova; e que os franqueados estariam praticando litigância de má-fé. Foi alegado, por fim, que “na hipótese de não se reconhecer o pedido dos Franqueados como justificados, tem-se que a rescisão deve ser reconhecida como injustificada, por iniciativa dos Autores/Reconvindos, uma vez que a Ré/Reconvinte jamais requereu e não requer, neste ato, a rescisão contratual”; que “na ocorrência de encerramento antecipado do Contrato, não havendo culpa da franqueadora na rescisão contratual, deve o franqueado arcar com a multa contratual pactuada”, bem como com o pagamento dos débitos a título de royalties.

A contestação com reconvenção foi instruída com documentos (fls. 543/688).

Foi regularizada a distribuição da reconvenção (fls. 692/1.083).

Houve réplica à contestação da ação e contestação à reconvenção (fls. 1.088/1.122), na qual, em síntese, foram reiteradas as alegações já sustentadas pelos franqueados na inicial.

Houve réplica à contestação da reconvenção (fls. 1.136/1.147).

As partes especificaram provas (fls. 1.151/1.155 e 1.156/1.160).

Foi acolhida a impugnação ao valor da causa da ação e determinada a complementação

das respectivas custas (fls. 1.161), sobrevindo manifestações da autora e determinações (fls. 1.164/1.167, 1.168, 1.171/1.172 e 1.188).

É o relatório. Passo a decidir.

2. Fundamentação

Inicialmente, afasto a preliminar de inépcia da petição inicial, tendo em vista que seus fundamentos se confundem com o mérito da demanda e serão com este apreciados.

Por outro lado, é caso de acolher a prejudicial de decadência do direito para postular a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.955/1994, vigente ao tempo em que pactuado o contrato de franquia entre as partes, pois a referida norma não estipulou prazo para o exercício do direito, de modo que aplicável a regra geral do art. 179 do CC, o qual estipula que "quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato".

Ora, a assinatura do contrato de franquia ocorreu em 02 de janeiro de 2018, e a presente ação só foi ajuizada em 29/10/2020, quando transcorridos mais de nove meses do decurso do prazo decadencial, de modo que configurada a decadência.

Como já decidiu o E. Tribunal de Justiça em casos similares:

Ação de rescisão de contrato de franquia, cumulada com pedidos indenizatórios, proposta por franqueada contra franqueadora. Sentença de improcedência. Apelação. Pedido de anulação do contrato, por vícios na circular de oferta de franquia. Decadência. Ausência de previsão de prazo para o ajuizamento de ação anulatória na Lei 8.955/94, devendo-se aplicar a regra geral do art. 179 do Código Civil, segundo o qual "quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato". Contagem do prazo decadencial a partir da assinatura do contrato. Ajuizamento da ação depois do biênio. Decadência corretamente pronunciada na origem. De todo o modo, ainda que assim não fosse, teria havido, e seria de se considerar, o transcurso de relevante período sem alegação, pelos franqueados, de falta de informações obrigatórias da circular de oferta de franquia. Enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Provas da efetiva prestação de assistência à franqueada. Há inúmeras variáveis que interferem na lucratividade da franquia, muitas delas fora do controle da franqueadora. Risco inerente às contratações entre empresários. Doutrina de ANTÔNIO MANUEL MENEZES CORDEIRO e PAULA FORGIONI. Manutenção da sentença recorrida. Apelação desprovida. (TJSP; Apelação Cível 1061329-60.2018.8.26.0100; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 03/05/2022; Data de Registro: 03/05/2022)

e

Ação anulatória de contrato de franquia c.c. indenizatória - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor - Não acolhimento - O prazo prescricional, para reparação dos danos (materiais e morais) derivados do suposto inadimplemento de obrigações contratuais, é de dez anos, nos termos do art. 205, do CC - A pretensão indenizatória (restituição da taxa de franquia, danos materiais e morais) não está prescrita - Decadência do direito de anulabilidade do contrato, pois inobservado o disposto no art. 179, do CC - Danos materiais não reconhecidos - Regular perda da taxa inicial de franquia, ante a rescisão imotivada do contrato - A situação vivenciada não enseja reparação moral - Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001066-65.2018.8.26.0681; Relator (a): Grava Brazil; Órgão

Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Louveira - Vara Única; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022)

Outrossim, observo que a produção probatória suplementar requerida pela parte autora também deve ser indeferida, pois a parte relevante dos fatos já está suficientemente evidenciada pela robusta documentação acostada aos autos (art. 370, parágrafo único, do CPC), como será melhor explicitado adiante.

A propósito, indefiro o pedido genérico de produção de prova documental suplementar formulado pelas partes, ressaltando-se que é ônus destas instruir a petição inicial, a reconvenção e as respectivas contestações com os documentos destinados a provar suas alegações, e que a juntada posterior de documentos deve ser admitida apenas excepcionalmente, à luz do art. 434 do CPC e dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

E indefiro também as provas oral e pericial pretendidas pelas partes, eis que a prova documental acostada aos autos é insuficiente para evidenciar minimamente a plausibilidade das alegações da parte autora-reconvinda quanto à existência de inadimplementos por parte da franqueadora, aptos a caracterizar a culpa desta pelo insucesso da unidade franqueada, demonstrando por outro lado a plausibilidade das alegações da franqueadora, como será melhor exposto adiante.

Assim, em suma, está configurada a hipótese de julgamento antecipado da lide (art. 353, I, do CPC), na medida em que a matéria de fato está satisfatoriamente provada por documentos.

Passo então à análise do mérito, ressaltando-se que o presente feito será analisado à luz da Lei nº 8.955/94, posto que o contrato de franquia foi pactuado entre as partes na vigência da referida norma, posteriormente revogada pela Lei nº 13.966/2019, de 26 de dezembro de 2019.

Pois bem.

Por determinação do art. 2º da 8.955/94, "Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício".

Ademais, acerca das obrigações essenciais vinculadas ao contrato de franquia, ensina Carlos D. A. Braga que "considerando os elementos essenciais do conceito de franquia empresarial (...) podemos identificar algumas obrigações características", sendo que "[a]s obrigações do franqueado consistem basicamente no seguinte: (i) realizar o pagamento da contraprestação devida em razão da licença de uso de marca e da prestação de serviços de assessoria técnica empresarial, normalmente dividida em uma taxa inicial (também chamada de taxa de franquia) e em pagamentos mensais calculados com base em um percentual sobre o faturamento do franqueado (royalties); (ii) oferecer aos consumidores apenas produtos ou serviços sob a marca licenciada pelo franqueador, por ele fabricados ou por quem ele indicar; (iii) observar estritamente as instruções de comercialização dos produtos e serviços estabelecidas pelo franqueador" e que "[a]s obrigações do franqueador, por sua vez, são: (i) conceder ao franqueado o direito de uso de sua marca; (ii) prestar os serviços de assessoria técnica de organização empresarial" (in Tratado de Direito Comercial, volume 6: estabelecimento empresarial, propriedade industrial e direito da concorrência. Fábio Ulhoa Coelho (coord.). São Paulo: Saraiva, 2015. pp. 181).

No caso dos autos, é incontroverso que, em 02 de janeiro de 2018, as partes

pactuaram contrato de franquia pertinente à operação de unidade da rede de clínicas médicas populares Partmed localizada no bairro de Laranjeiras, Serra-ES, com prazo de vigência de 5 anos, o que também é evidenciado pela documentação acostada aos autos (fls. 61/93, dentre outras).

Nesse contexto, prejudicada a pretensão anulatória em razão do reconhecimento da decadência, a parte autora-reconvinda postula a declaração de rescisão do contrato de franquia por culpa da franqueadora, com a condenação desta ao pagamento de multa contratual, à restituição de valores e ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, em razão de inadimplementos contratuais diversos, e a declaração de inexigibilidade de obrigações contratuais, em particular, quanto ao pagamento dos royalties e à não concorrência.

Ocorre, entretanto, que há que se reconhecer a improcedência do pedido de rescisão do contrato de franquia por culpa da franqueadora, visto que as alegações que a fundamentam não encontram lastro no conjunto probatório acostado aos autos, que, na verdade, evidencia que a franqueadora adimpliu plena e regularmente suas obrigações contratuais.

Nesse sentido, a documentação acostada aos autos na verdade comprova que as partes mantinham frequente comunicação por e-mail, que a franqueadora deu treinamentos, suporte operacional, de publicidade e de informática à parte autora, por diversas vezes, durante o prazo de vigência do contrato, e que os problemas pontuais e específicos encontrados não fugiram à normalidade de um negócio jurídico complexo e de execução continuada, inexistindo documentos aptos a demonstrar que a parte autora tenha realizado de forma consistente quaisquer reclamações pertinentes aos atos imputados à franqueadora - aliás, não há nos autos qualquer registro de reclamação anterior às duas sequências de e-mails em que os franqueados comunicaram a intenção de extinguir o negócio.

Ademais, em que pese a gravidade das alegações dos franqueados quanto à seleção ou ainda imposição de local inadequado para estabelecer a unidade franqueada por parte da franqueadora, não há nos autos qualquer evidência de que tal assertiva seja verdadeira, havendo por outro lado prova de que a mudança do território de Vila Velha para Serra/ES se deu a pedido dos franqueados (fls. 365/372).

E ressalte-se que natureza do contrato pactuado é eminentemente empresarial, presumindo-se situação de relativa igualdade, de modo que a vontade das partes deve ser prestigiada e que o exercício de atividade empresarial pressupõe a existência de risco do negócio.

Como ensina Paula Forgioni, o funcionamento do mercado exige que os pactos sejam respeitados, de forma que "A força obrigatória dos contratos viabiliza a existência do mercado, coibindo o oportunismo indesejável das empresas" (in Contratos Empresariais. Teoria e Aplicação, 3ª ed., pp. 109/112, São Paulo, RT, 2018).

Ainda sobre o *pacta sunt servanda*, a Professora aponta que "Se lhes fosse permitido, os agentes econômicos valer-se-iam dos contratos para vincular apenas seus parceiros comerciais, e nunca a si próprios. No momento inicial, as partes creem que o negócio ser-lhes-á vantajoso; todavia, com o passar do tempo, é possível que o vínculo deixe de interessar a uma delas. Nasce anseio de se livrar da amarra contratual para seguir outro caminho. Partindo dessa premissa, compreende-se a importância sistêmica da força vinculante dos contratos; na sua ausência, seria impossível a coibição do descumprimento da palavra empenhada e o desestímulo de comportamentos oportunistas prejudiciais ao tráfico. O princípio do "*pacta sunt servanda*" mostra-se necessário ao giro mercantil na medida em que freia o natural oportunismo dos agentes econômicos" (op. cit. - grifado).

Conclui-se, assim, que o insucesso da parte autora não pode ser atribuído à ré sem

que tenha sido, sequer, demonstrado o inadimplemento do contrato, restando portanto improcedente a pretensão pela declaração de que a rescisão do contrato se deu por culpa da franqueadora.

Em segundo lugar, subsistindo a rescisão imotivada do negócio, há que se julgar parcialmente procedente a demanda da franqueadora quanto à condenação dos franqueados ao pagamento da multa contratual estipulada na cláusula 18.3 do contrato de franquia, assim redigida (fl. 83):

18.3 Caso o(a) FRANQUEADO(A) pretenda a rescisão injustificada do presente contrato, após a realização do treinamento inicial de executivos, o mesmo deveá a FRANQUEADORA, via correio através de carta registrada com aviso de recebimento ou Cartório de Títulos e Documentos, com 60 (...) dias de antecedência e arcar com multa de R\$ 100.000,00 (...) em favor da FRANQUEADORA, bem como arcar com todos os valores que forem devidos à FRANQUEADORA e à fornecedores, que estiverem em aberto.

Porém, cabe a redução proporcional do valor postulado a título de multa, a teor do disposto no art. 413 do CC.

Assim, é devido o pagamento proporcional da multa de R\$ 100.000,00 pelo tempo restante para o término do contrato com prazo de vigência de 5 anos, tendo em vista que o termo do referido prazo se daria em 08/01/2023, acrescida de correção monetária pelo IGP-M/FGV desde a data da assinatura do contrato de franquia (cláusula 22.7 - fls. 87), e de juros de mora de 1% a.m. desde a data em que se operou a rescisão; e que, à míngua da indicação de data específica, a rescisão se operou 60 dias após o comparecimento espontâneo da parte ré nos presente demanda, ou seja, em 15/01/2021.

E, posto que os franqueados sequer impugnaram o alegado inadimplemento, há também que se reconhecer a procedência da pretensão da franqueadora quanto à condenação dos franqueados ao pagamento dos débitos a título de royalties indicados como "saldo em aberto" nos documentos de fls. 687 e 688, no valor total de R\$ 3.035,11, acrescidos de multa correspondente a 2% do valor dos débitos, de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária pelo índice IGPM-FGV (cláusula 6.4 - fls. 68), desde a data dos respectivos inadimplementos.

Por fim, não assiste razão aos franqueados quanto à nulidade da cláusula de não-concorrência, em específico.

Com relação à referida obrigação, assim prevê o contrato de franquia:

17.5. Após a extinção do presente contrato, o(a) FRANQUEADO(A) compromete-se ainda pelo período de 2 (dois) anos, caso haja a rescisão por qualquer das hipóteses avançadas e, até mesmo com o término de seu prazo, a não participar seja como sócio proprietário ou contratado, de qualquer estabelecimento que preste serviços médicos, ou em estabelecimento que utilize a metodologia e tecnologia adotada especificamente pela FRANQUEADORA, não havendo restrição ao exercício da profissão de médico, sem a utilização de marca ou bandeira, e sem a aplicação metodologia da FRANQUEADORA.

17.6. Após a extinção do presente contrato, o(a) FRANQUEADO(A) compromete-se ainda pelo período de 2 (dois) anos, caso haja a rescisão por qualquer das hipóteses avançadas e, até mesmo com o término de seu prazo, a não constituir, participar seja como sócio ou acionista, como proprietário, como contratado ou como máster franqueado, de empresa franqueada que comercialize o direito de uso de marca e/ou tecnologia para empresas que prestem serviços médicos (fls. 81/82)

E, como ensina Fábio Ulhoa Coelho:

As cláusulas contratuais de disciplina da concorrência podem ou não ser válidas, de

acordo com uma série de fatores, a serem especificamente analisados. Para a análise, o critério mais relevante é o da preservação do livre mercado. Ou seja, as partes podem disciplinar o exercício da concorrência entre elas, desde que não a eliminem por completo. Em outros termos, a validade da disciplina contratual da concorrência depende da preservação de margem para a competição (ainda que futura) entre os contratantes; ou seja, da definição de limites materiais, temporais e espaciais. Em concreto, a vedação não pode dizer respeito a todas as atividades econômicas, nem deixar de possuir delimitações no tempo ou no espaço.

Em relação aos limites materiais, observa-se que a cláusula disciplinando a concorrência é inválida, se impede o contratante de explorar qualquer atividade econômica. A restrição deve necessariamente se circunscrever a determinados ramos de comércio, indústria ou serviços. Para as demais atividades, as partes ficam livres de qualquer obrigação (de não fazer). A propósito da restrição material, deve-se também considerar inválida a cláusula que impeça o contratante, pessoa física, de exercer a sua profissão. Por exemplo, o sócio que se desliga de sociedade de engenheiros pode, no instrumento de cessão de cotas, ficar impedido de competir com a sociedade, desde que os termos contratados não alcancem todas as atividades de engenharia para as quais o retirante se encontra profissionalmente habilitado ou preparado.

Também é inválida a cláusula que vede a concorrência para sempre ou em qualquer lugar. Limites temporais ou espaciais são exigidos, para que a restrição contratada não importe eliminação total da concorrência. Trata-se, aqui, de uma alternativa inclusiva; ou dizer, o contrato pode prever limite no tempo e no espaço, ou só num deles. A restrição contratual limitada apenas geograficamente se considera feita para sempre, enquanto a limitada apenas no tempo alcança todos os mercados (Ripert-Roblot, 1947:350). A invalidade existe quando não há simultaneamente limite temporal e espacial. É igualmente inválida a cláusula de não concorrência que estabelece prazo demasiado longo, ou defina limites espaciais exagerados, que ultrapassem o potencial de conquista de mercado que as partes possuem. Desse modo, é nula a cláusula de não estabelecimento que o empreendedor de shopping center, para evitar a concorrência autofágica, contrata com os lojistas, quando os limites territoriais nela referidos extrapolam os do mercado sobre o qual pode exercer atração (in Curso de Direito Comercial, v. 1, cap. 7, São Paulo, RT, 2018 - grifado).

E, tendo em vista a ressalva constante na parte final da cláusula 17.5, não há nulidade na obrigação de não concorrência prevista pelo contrato, eis que restringe a atuação dos franqueados, por 2 anos, como médicos em estabelecimentos que sejam objeto de contrato de franquia ou ainda que atuem mediante a cessão de uso de marca, e que não há restrições, em análise preliminar, ao exercício da medicina em consultórios particulares ou ainda em hospitais, por exemplo, desde que "sem a utilização de marca ou bandeira, e sem a aplicação metodologia da FRANQUEADORA".

Assim, está evidenciada a improcedência da ação e a parcial procedência da reconvenção.

3. Dispositivo

Diante do exposto, julgo a ação improcedente e a reconvenção parcialmente procedente, para:

a) com relação à pretensão dos autores-reconvindos pela anulação do contrato de franquia que é objeto do feito nos termos do art. 4º da Lei nº 8.955/1994, vigente ao tempo em que este foi pactuado, determinar a extinção do processo nos termos do art. 487, II, do CPC;

b) com relação às demais pretensões dos autores-reconvindos e da ré-reconvinte, determinar a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do CPC;

- c) declarar a rescisão imotivada do contrato de franquia pactuado entre as partes;
- d) condenar os autores-reconvindos ao pagamento proporcional da multa de R\$ 100.000,00 pelo tempo restante para o término do contrato com prazo de vigência de 5 anos, tendo em vista que o termo do referido prazo se daria em 08/01/2023, acrescida de correção monetária pelo IGP-M/FGV desde a data da assinatura do contrato de franquia (cláusula 22.7 – fls. 87), e de juros de mora de 1% a.m. desde a data em que se operou a rescisão; e que, à míngua da indicação de data específica, a rescisão se operou 60 dias após o comparecimento espontâneo da parte ré nos presente demanda, ou seja, em 15/01/2021;
- e) condenar os autores-reconvindos ao pagamento dos débitos a título de royalties indicados como “saldo em aberto” nos documentos de fls. 687 e 688, no valor total de R\$ 3.035,11, acrescidos de multa correspondente a 2% do valor dos débitos, de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária pelo índice IGPM-FGV (cláusula 6.4 – fls. 68), desde a data dos respectivos inadimplementos;
- f) determinar que a apuração dos valores devidos depende de mero cálculo aritmético (art. 509, § 2º, do CPC), que deverá ser elaborado diretamente pelo credor;
- g) com fundamento no – art. 85, § 2º, do CPC, condeno os autores-reconvindos ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado pelo réu, fixados em 10% do valor da condenação. Observo que em relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da condenação. Em relação aos honorários advocatícios, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA